

NOOR AZLINA BINTI MOHD SAPAWI

lawan

EJAZ BIN ABDUL KAYUM

[Mahkamah Rayuan Syariah Selangor, YAA Tuan Mohd Amran Bin Mat Zain (Pengerusi), YA Dato' Mohamad Shakir bin Abdul Hamid (Ahli Panel), YA Tuan Othman bin Ibrahim (Ahli Panel)]

Pada : 6hb November 2020 / 20 Rabiul Awal 1442H

Kes Mal (Semakan) No. 10000-003-0089-2020

[Permohonan Semakan Perintah Interim Secara Interparte]

Peguam Syarie Pemohon : Tetuan Irsamuddin Fitri & Associates

ALASAN PENGHAKIMAN

Permohonan

[1] Pemohon memfailkan permohonan di Mahkamah Yang Mulia ini untuk mendapatkan suatu perintah sebagaimana berikut :

- i. Mahkamah Rayuan Syariah membatalkan keseluruhan Perintah Sementara bertarikh 7/9/2020 berkenaan Hak Lawatan dan Bermalam bagi anak yang bernama Saif Umar bin Ejaz (No Mykid : 140810-10-1407) kepada Responden, Ejaz bin Abdul Kayum (No. Kp : 731202-07-5705) yang diputuskan di dalam kes induk Hak Lawatan dan Bermalam di dalam saman no. 10100-028-0156-2018 oleh YA Hakim Bicara Mahkamah Tinggi Syariah seperti berikut:-

- a. *Mahkamah memerintahkan Plaintiff diberikan hak lawatan dan bermalam bersama dengan anak yang bernama Saif Umar bin*

Ejaz (No Mykid : 140810-10-1407) [selepas ini disebut sebagai "Anak Tersebut" selama dua (2) hari iaitu pada hujung minggu pertama (1) dan minggu ketiga (3) setiap bulan.

- b. Mahkamah memerintahkan hak lawatan dan bermalam tersebut boleh dilakukan dimana-mana tempat di Negeri Johor atau negeri Selangor.*
 - c. Mahkamah memerintahkan Plaintiff tidak dibenarkan membawa keluar anak tersebut dari negeri di mana tempat anak tersebut diambil.*
 - d. Mahkamah memerintahkan bahawa pihak Polis Di Raja Malaysia dan mana-mana pihak berkuasa hendaklah membantu agar Perintah Sementara ini dapat dilaksanakan dengan baik jika pihak Plaintiff memerlukan bantuan proses pelaksanaan Perintah Sementara ini demi keselamatan anak tersebut semasa sesi lawatan dan bermalam dengan Plaintiff.*
 - e. Mahkamah memerintahkan Perintah Sementara ini hendaklah berkuakusa sehingga kes saman no. 10100-028-0156-2018 diputuskan sepenuhnya.*
 - f. Mahkamah memerintahkan kemungkiran terhadap Perintah Sementara ini adalah dianggap sebagai penghinaan Mahkamah.*
- ii. Lain-lain perintah yang difikirkan adil dan suai manfaat oleh Mahkamah Yang Mulai ini.

Fakta Kes

[2] Pemohon dan Responden di dalam perkahwinan mereka telah dikurniakan dengan seorang (1) orang anak iaitu Saif Umar bin Ejaz (No Mykid : 140810-10-1407) yang kini berusia 6 tahun (selepas ini disebut sebagai anak-anak tersebut).

[3] Pada 21/2/2012018, Responden telah memfailkan tuntutan Kes Hak Lawatan dan Bermalam di dalam saman no. 10100-028-0156-2018 terhadap anak tersebut dan masih diperingkat perbicaraan di Mahkamah Tinggi Syariah.

[4] Menurut Pemohon, semasa prosiding kes tuntutan Kes Hak Lawatan dan Bermalam tersebut, tanpa permohonan daripada Peguam Syarie Responden, Hakim Bicara telah memutuskan suatu perintah sementara seperti dalam perenggan 1 di atas.

[5] Pemohon tidak berpuashati dengan keputusan tersebut dan memfailkan permohonan semakan ini. Berdasarkan kepada Afidavit Permohonan Pemohon, isu sahaja yang dibangkitkan Pemohon bagi menyokong permohonannya seperti dalam Afidavit Pemohon bertarikh 14/9/2020 adalah berhubung dengan kebajikan anak tersebut yang secara material adalah bercanggah dengan undang-undang dan hukum Syarak.

Ulasan Mahkamah Rayuan Syariah

[6] Sukacita kami tegaskan di sini bahawa permohonan semakan terhadap keputusan atau penghakiman Mahkamah Tinggi Syariah di bawah seksyen 68

Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 tidak boleh dibenarkan secara sewenang-wenangnya kerana proses semakan adalah menyemak rekod kes tanpa proses pendengaran dari kedua-dua belah pihak. Ringkasnya, apabila pihak-pihak terkilan dengan apa-apa keputusan atau penghakiman, pihak-pihak tidak boleh sewenang-wenangnya mengguna pakai permohonan semakan ini untuk mendapatkan apa-apa *remedi* atau penghakiman untuk memperbetulkan apa-apa perintah yang telah dikeluarkan itu.

[7] Arahan Amalan No. 7 Tahun 2014 (*Peraturan Semakan Kes Di Mahkamah Tinggi Syariah Atau Di Mahkamah Rayuan Syariah*) telah menetapkan kriteria-kriteria kes yang boleh disemak melalui peruntukan seksyen 68 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003.

[8] Panel Rayuan Syariah melalui pelbagai kes semakan di Mahkamah Rayuan Syariah Negeri-Negeri juga telah menggariskan beberapa panduan agar proses semakan ini hanya boleh dilaksanakan ke atas kes-kes atau isu-isu yang tertentu sahaja seperti kes Mokhtar Bin Yusup lwn. Nurin Binti Abdullah, JH 36 (2), kes Mahmud Abu Bekir Taib lwn Shahnaz A. Majid, Kes Mal (Semakan) Wilayah Persekutuan No. 14000-003-0033-2012, kes Khadrishah Bin Khalid lwn. Fadhilah Binti Othman, Kes Mal (Semakan) Wilayah Persekutuan No. 10000-003-0009-2011, Kes Adi Asri b. Baharom lwn. Andini Nidia Putra, Kes Mal (Semakan) Selangor No. 10000-003-0015-2012.

[9] Berdasarkan kepada Arahan Amalan dan panduan otoriti kes-kes di atas, maka kesimpulan yang boleh dibuat ialah permohonan semakan hanya boleh dibenarkan apabila telah berlaku kesilapan, kecacatan atau kecederaan yang secara material bercanggah dengan prinsip undang-undang dan hukum Syarak sepanjang prosiding berlangsung di hadapan Hakim Bicara atau

perintah / penghakiman Hakim Bicara yang dikeluarkannya ternyata membelakangkan undang-undang yang sedang berkuatkuasa atau menyalah nas dan Hukum Syarak sehingga menyebabkan kepentingan keadilan pihak-pihak atau mana-mana pihak dinafikan serta diabaikan.

[10] Bagi melaksanakan semakan ini, kami telah memanggil dan menyemak rekod kes no. 10100-028-0156-2018. Penelitian terhadap fail atau rekod kes tersebut sangat penting kerana proses semakan ialah untuk mengenalpasti apakah adanya apa-apa kecacatan sepanjang perbicaraan atau kecacatan terhadap mana-mana perintah sama ada kecacatan dari segi undang-undang atau kekhilafan hukum Syarak.

[11] Merujuk kepada Afidavit Sokongan Pemohon, dalam **Alasan Pertama** permohonan semakan, Pemohon mendakwa bahawa perintah yang dikeluarkan oleh Hakim Bicara adalah bercanggah dan bertentangan dengan prinsip keadilan, kebajikan dan kemaslahatan anak tersebut dari segi undang-undang dan hukum Syarak apabila tidak menimbang secara adil dan berhemah berhubung kebajikan dan kemaslahatan anak tersebut yang berusia 6 tahun. Hakim Bicara mengeluarkan perintah hak lawatan dan bermalam sedangkan menurut Pemohon anak tersebut tidak mengenali dan hanya sekali berjumpa dengan Responden sebagai bapanya sejak mereka tinggal berasingan dari tahun 2016.

Pemohon juga menyatakan Hakim Bicara telah terkhilaf apabila mengeluarkan perintah sementara kepada Responden sedangkan tiada permohonan perintah sementara daripada pihak Responden atau Peguam Syarie Responden.

[12] Sukacita kami nyatakan bahawa prosiding permohonan perintah interim hadhanah ini adalah berbeza dengan prosiding kes induk hadhanah, di mana dalam prosiding interim hadhanah, Hakim Bicara hanya menilai dan mempertimbangkan berdasarkan kertas kausa yang dikemukakan tanpa berpeluang untuk mendengar keterangan pihak-pihak secara menyeluruh serta membuat penilaian terhadap pembuktian yang dikemukakan seperti mana kes induk hadhanah.

[13] Merujuk kepada perintah Hakim Bicara bertarikh 7/9/2020, kami dapati Hakim Bicara telah tidak memberikan apa-apa alasan atau justifikasi apabila mengeluarkan perintah hak lawatan dan bermalam kepada Responden (bapa) terhadap anak tersebut yang kini berusia 6 tahun yang secara material tidak pernah berpisah dengan Pemohon (ibu).

[14] Dapatan kami bahawa perintah tersebut telah wujud prinsip yang menghalang keadilan, kebajikan dan kemaslahatan terhadap anak tersebut, di mana perintah tersebut telah memberi hak bermalam dengan anak tersebut kepada Responden sedangkan berdasarkan fakta dalam kes induk jelas menunjukkan anak tersebut sejak 26/2/2016 ketika berumur 2 tahun tidak pernah bertemu dengan Responden.

[15] Bagi kes hadhanah ini, kemaslahatan terhadap anak tersebut yang lebih diutamakan berbanding kemaslahatan pihak-pihak. Ini telah dijelaskan di dalam kitab *Fiqh As-Sunnah, Syed Sabiq Juz 8 halaman 219* yang menyatakan:-

إن لكل من الحضانة والمحضون حقا في الحضانة, إلا أن حق المحضون أقوى
من الحضانة

Bermaksud:

“Sesungguhnya setiap penjaga dan anak jagaan masing-masing mempunyai hak. Akan tetapi hak anak atau kemaslahatan anak lebih penting dari hak penjaganya”

[16] Perkara yang sama juga telah diulas oleh Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Kelantan di dalam kes Mohd Radhi bin Haji Che Daud lwn Khadijah binti Yaacob[2004] JH 17(1) iaitu -

“Tujuan hadhanah atau penjagaan kanak-kanak ialah untuk masalah dan kebaikan kanak-kanak yang dipelihara sebagai hak asasi bagi kanak-kanak itu dan hak itu mesti diutamakan lebih dari hak pihak yang ingin memelihara mereka.”

[17] Oleh yang demikian, kami berpuashati dan menyatakan bahawa soal kemaslahatan anak tersebut adalah lebih utama berbanding dengan kemaslahatan pihak-pihak. Perasaan kanak-kanak adalah elemen utama yang harus dijaga dan dititikberatkan, dan Hakim Bicara perlu menilai dan mempertimbangkan perkara tersebut sebelum suatu keputusan dibuat.

[18] Kami berpandangan adalah tidak wajar dan masih belum sesuai untuk memerintahkan hak bermalam kepada Responden kerana anak tersebut sejak kecil tidak berjumpa dengan bapanya, yang pasti mendatangkan situasi tidak selesa kepada anak tersebut. Keadaan ini juga berkemungkinan menjadi penyebab terganggunya emosi dan mental anak tersebut setiap kali sesi lawatan dan bermalam berlangsung.

[19] Walau bagaimanapun, hak lawatan dan bermesra dengan anak tersebut wajar diberikan bagi membiasakan anak tersebut bersama Responden. Ini bertujuan merapatkan hubungan dan ikatan yang lebih mesra antara anak tersebut dan Responden sebelum kes induk diputuskan.

[20] Disebutkan oleh *Dr. Wahbah al-Zuhaili, 1997M/1418H, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu. Juz. 10, Damsyiq: Dar al-Fikr, cet. 4, hlm. 7320* seperti berikut:

حق الرؤية أو الزيارة لأحد الأبوين غير الحاضن مقرر شرعا باتفاق
الفقهاء , لصلة الرحم , ولكن ذكروا آراء مختلفة نسبيا , بحسب تقدير
المصلحة لكل من الولد والوالد الذي يكون ولده في حضانة غيره .

Bermaksud:

“Ahli fiqh Islam bersependapat bahawa satu ketetapan dalam syara’ iaitu ibu atau bapa berhak melihat atau menziarahi anak yang tidak berada di bawah jagaannya kerana hubungan silaturrahim. Namun begitu menyebutkan beberapa pendapat yang berbeza secara nisbah dengan mengambil kira kadar masalah bagi anak dan bapa yang anaknya di bawah jagaan orang lain.”

[21] Berdasarkan kepada ulasan kami di atas, maka kami bersetuju bahawa Hakim Bicara telah terkhilaf sehingga menjejaskan keadilan kepada anak tersebut apabila membuat keputusan tanpa memberikan apa-apa alasan atau justifikasi serta tidak merujuk kepada peruntukan-peruntukan yang berkaitan.

Oleh yang demikian adalah wajar untuk kami campur tangan terhadap perintah hak jagaan sementara yang bertarikh 7/9/2020 tersebut.

[22] Demi kebajikan anak tersebut juga, kami menegaskan bahawa pertikaian antara Pemohon dan Responden di dalam kes induk perlulah disegerakan. Permohonan yang bersifat interlokutori selepas ini sebolehnya tidak digalakkan kerana ianya boleh melambatkan penyelesaian muktamad di dalam kes induk.

KEPUTUSAN

SETELAH Kami membaca, meneliti permohonan semakan Pemohon dan setelah menyemak rekod kes no. 10100-028-0156-2018, MAKA Kami sebulat suara memutuskan bahawa :-

1. Permohonan semakan oleh Pemohon **DITERIMA**.
2. Perintah Sementara bertarikh 20/11/2017 **DIUBAH** seperti berikut:-
 - i. *Mahkamah memerintahkan Responden (bapa) diberikan hak lawatan dengan anak yang bernama Saif Umar bin Ejaz (No Mykid : 140810-10-1407) setiap hari Sabtu pada minggu pertama (1) dan minggu ketiga (3) setiap bulan bermula jam 9.00 pagi hingga 6.00 petang.*
 - ii. *Mahkamah memerintahkan hak lawatan tersebut boleh dilakukan dimana-mana tempat di negeri di mana anak tersebut menetap/tinggal.*
 - iii. *Mahkamah memerintahkan Responden tidak dibenarkan membawa keluar anak tersebut dari negeri di mana tempat anak tersebut diambil.*
 - iv. *Mahkamah memerintahkan bahawa pihak Polis Di Raja Malaysia dan mana-mana pihak berkuasa hendaklah membantu agar Perintah Sementara ini dapat dilaksanakan dengan baik jika pihak-pihak memerlukan bantuan proses pelaksanaan Perintah Sementara ini demi keselamatan anak tersebut semasa sesi lawatan bersama Responden.*
3. Prosiding kes induk di Mahkamah Tinggi Syariah Selangor hendaklah **DISEGERAKAN**.

Dibaca dan ditandatangani oleh:-



-
1. **YAA TUAN MOHD AMRAN BIN MAT ZAIN**
Pengerusi
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-



-
2. **YA DATO' MOHAMAD SHAKIR BIN ABDUL HAMID**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-



-
3. **YA TUAN OTHMAN BIN IBRAHIM**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

